

1500491-90.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500491-90.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-90.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE APARECIDO LEANDRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Henrique Aparecido Leandro e Pâmela Tamara Januário de Paula dando-os como incurso nas sanções do art. 33 c.c 40, VI, da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls. 134/136):

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 1º de março de 2021, por volta das 13h30, na Rua Caiçara, 104, Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Catanduva/SP, HENRIQUE APARECIDO LEANDRO, qualificado à fls. 7, e PAMELA TAMARA JANUARIO DE PAULA, qualificada a fls. 9, juntamente com a adolescente Emily Anastacio Santos, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam e guardavam consigo drogas, consistente em 218 (duzentos e dezoito) pinos de crack e 3 porções de maconha, a fim de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 19/21.

Segundo apurado, os denunciados, marido e mulher, com a ajuda da adolescente Emily Anastacio Santos, traziam e guardavam consigo as drogas mencionadas, para a entrega a terceiros, quando ambos foram surpreendidos pela polícia militar.

Policiais militares avistaram a adolescente em um lugar muito conhecido pela

prática do tráfico de drogas, trazendo consigo uma bolsinha, apresentando comportamento suspeito. Resolveram abordá-la encontrando com ela, no interior da referida bolsa, 17 (dezessete) pinos de crack, 3 (três) porções de maconha e R\$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos em dinheiro). Ela confessou a traficância e disse que Henrique e Pamela, usando o veículo Vectra cinza, haviam acabado de deixar a droga para ela vender e outra quantidade ficava guardada em um terreno baldio, onde havia mais 98 (noventa e oito) pinos de crack.

Outra equipe policial foi comunicada acerca da denúncia contra os denunciados e abordaram-nos na via pública. Sob o banco dianteiro do passageiro, onde Pamela estava sentada, havia uma bucha contendo 26 (vinte e seis) pinos de crack e dois aparelhos celulares. Ambos confessaram o tráfico e confirmaram haver mais drogas guardadas na residência. Diligenciaram até lá, onde os policiais localizaram mais três buchas contendo 77 (setenta e sete) pinos de crack e R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva no dia seguinte (fls. 73/76), mas a ré alcançou liberdade provisória em 28 de abril de 2021, no bojo de habeas corpus (fls. 158/171).

Defesa preliminar sem abordagem do mérito (fls. 201/203).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2021 (fl. 214).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas, uma informante e interrogados os imputados, que refutam a prática do ilícito.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal (fls. 358/364), ao passo que a Defesa roga pela absolvição em vista da insuficiência probatória e, subsidiariamente, por benesses atinentes à aplicação da pena (fls. 373/389 e 390/399).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa a Henrique Aparecido Leandro e Pâmela Tamara Januário de Paula a infração penal prevista no art. 33 c.c 40, VI, da Lei 11.343/06.

Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 19/21 e 111/113) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre os ora réus.

Com efeito, o policial militar Ivan Maglio, declarou, em síntese, que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina em localidade conhecida pela intensa traficância de drogas quando avistou a adolescente Emily portando uma bolsa e decidiu abordá-la, o que resultou na apreensão de crack e de maconha. Narrou que a adolescente lhe informou que havia recebido as drogas dos ora acusados, os quais estavam em um veículo GM/Vectra. Acrescentou que a adolescente ainda indicou o local onde havia mais drogas escondidas, sendo que lá os policiais encontraram noventa e oito pinos de crack. Esclareceu que não realizou a abordagem dos réus, eis que repassou a informação para outra guarnição.

O policial militar Ricardo Silva Rosa, por sua vez, declarou que o policial Ivan Maglio lhe informou que uma adolescente havia sido abordada com drogas, as quais teriam sido fornecidas por um casal que estava em um veículo GM/Vectra. Narrou que continuou o patrulhamento, encontrou o mencionado automóvel e procedeu à abordagem, logrando apreender vinte e seis pinos de crack que estavam escondidos embaixo do banco do passageiro. Acrescentou que o casal confirmou possuir mais drogas em casa, motivo pelo qual diligenciou até lá e recolheu mais pinos de crack.

A adolescente Emily Anastácio Santos, quando ouvida em Juízo, negou os fatos narrados pelos milicianos. Disse que na data dos fatos estava caminhando em via pública, pois iria colher seriguelas, quando foi abordada pelos policiais, os quais

a orientaram a assumir a propriedade das drogas ao argumento de que ela não sofreria responsabilizações, já que era menor. Refutou, inclusive, conhecer os réus.

Henrique e Pâmela, quando interrogados, negaram veementemente a prática ilícita, refutando o envolvimento com o tráfico de drogas, a posse e propriedade de substâncias entorpecentes e o fornecimento delas à adolescente Emily. Afirmaram, ademais, que a ação policial foi eivada de abusos e inclusive agressões físicas. Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se infere que as negativas trazidas pelos réus não encontram respaldo, pois não são minimamente corroboradas por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige inferir que as drogas apreendidas foram plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória.

Lado outro, os testemunhos dos policiais militares são firmes, uníssonos, detalhados e coesos.

No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas.

Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530;

Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de

prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda.

Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, é de se ver que a combativa Defesa não apresenta qualquer elemento objetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos, dentre os quais vale destacar, uma vez mais, a apreensão das substâncias entorpecentes e, sobretudo, as declarações prestadas pela adolescente Emily em sede policial, na presença da defensora constituída pelos acusados.

Veja-se, no ponto, o teor das declarações de Emily durante a fase pré-processual, no dia de sua apreensão em flagrante, diante da autoridade policial, de sua genitora e, repita-se, da defensora dos acusados (fl. 05):

Sabendo ler e escrever, declarou que: Na presença da Dra. Fernanda Cristina José de Souza-OAB-SP-354047 e de sua genitora Rosilene de Jesus Anastacio, quanto aos fatos abre mão de seu direito de permanecer calada para informar que a menos de uma

semana vem vendendo crack para o autuado Henrique. Na tarde de hoje, se encontrava na biqueira quando Henrique chegou no local com um veículo de cor cinza, estando acompanhado pela esposa Pamela, tendo deixado com a declarante uma bucha contendo porções de crack no valor de R\$ 250,00. Já tinha vendido algumas porções da droga quando foi abordada pelos policiais militares, os quais encontraram o entorpecente na posse da declarante. Ao ser indagada, acabou confessando informalmente os fatos acima relatados aos militares. Tinha ciência de que Henrique escondia 04 buchas de crack em uma casa abandonada situada nas imediações. Levou os policiais até esse imóvel, onde o entorpecente foi apreendido. Nunca se envolveu em ocorrências policiais, não registrando antecedente infracional. Tomou conhecimento de que os policiais militares abordaram o casal na via pública.

Bem verdade que em Juízo a adolescente trouxe história completamente diferente que, há de se convir, é de parca credibilidade. Isso porque ela narrou que estava caminhando na via pública quando os policiais militares lhe pediram para simplesmente assumir a propriedade da droga ao argumento de que não seria responsabilizada por ser inimputável – motivo pelo qual ela atendeu ao pleito. Ora, a adolescente, à época dos fatos, já possuía dezesseis anos de idade e aparenta ser bem instruída, do que se depreende que, conquanto seja inimputável, tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e não confessaria a prática infracional pura e simplesmente, diante de sua genitora e da advogada dos réus, sem que os fatos efetivamente tivessem ocorrido. A versão que deve prevalecer, portanto, é por ela prestada à autoridade policial.

Ademais, se o escopo dos policiais fosse forjar o flagrante em desfavor dos acusados, era prescindível o envolvimento da adolescente no cenário, pois bastaria a posse de drogas e a abordagem dos réus. Mas não, houve prévia apreensão de drogas com a inimputável que, por seu turno, repassou as informações aos policiais.

Assim sendo, é de rigor reconhecer que, diante da narrativa da adolescente e da apreensão das substâncias entorpecentes no automóvel em que estavam os réus e no domicílio deles, o édito condenatório se impõe, inclusive com a incidência da causa de aumento de pena decorrente do envolvimento de adolescente no fato – cujo quantum de incidência será apreciado por ocasião da fixação da reprimenda.

Destarte, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 c.c 40, VI, da Lei 11.343/06 está cabalmente comprovada nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Primeiramente, fixo a pena da acusada Pamela.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida, diante do número de agentes e do contexto fático, não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. A ré não ostenta antecedentes. A conduta social e a personalidade, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias do crime não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante atinente à menoridade (art. 65, I, do CP), mas, diante da ausência de agravantes e do disposto na Súmula 231 do STJ, deixo de valorá-la, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque, a ré é primária, ostenta bons antecedentes e não há notícias fundadas de que ela se dedique às atividades delituosas ou integre organização criminosas, de modo que deve ser aplicado o redutor em seu patamar máximo, qual seja de dois terços.

Presente, lado outro, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente na empreitada. Considerando as circunstâncias pessoais da ré e também da adolescente, que não apresenta outras anotações nem parece estar integrada ao tráfico de drogas, justifica-se o aumento no patamar mínimo, qual seja de um terço.

Assim fixo, a pena definitiva da acusada Pâmela em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade financeira da acusada.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, diante das circunstâncias pessoais absolutamente favoráveis, da quantidade de pena aplicada, do disposto no art. 33, §2º, 'c', do CP, e na Súmula 440 do STJ, só pode ser o aberto.

Ademais, conquanto originariamente o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 vedasse a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, tal previsão foi julgada inconstitucional pelo C. STF, por violação ao direito fundamental de individualização da pena. Posteriormente, foi publicada a Resolução n. 5 do Senado Federal, que, com efeito erga omnes, suspendeu a vedação legal e impôs ao julgador o dever de verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Nessa linha, tendo em vista que, no caso, a ré é primária, que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, da Lei 11.343/06, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos, a ser paga à entidade pública ou privada com destinação social determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquela da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa.

Passo, agora, à dosimetria da pena do acusado Henrique.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida, diante do número de agentes e do contexto fático, não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de forma que utilizo uma delas (autos n. 0025856-67.2012.8.26.0576) nesta fase e relego as outras para a etapa seguinte, evitando, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). A conduta social e a personalidade, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias do crime não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63, ambos do CP), em vista da condenação definitiva nos autos n. 0021932-77.2014.8.26.0576). Por isso, agravo a pena intermediária em um sexto e a fixo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição de pena, pois a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é obstada pela reincidência e pelos maus antecedentes do agente. Lado outro, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343, que enseja o incremento da pena em um terço. Logo, a pena definitiva fica estabelecida em 09 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'a', e 3º, do CP, e da reincidência. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Ainda em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

CONDENAR a Pâmela Tamara Januário de Paula como incurso nas sanções do art. 33, §4º, c.c 40, VI, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 221 dias-multa de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de liberdade resta substituída pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária no valor de cinco salários-mínimos, a ser paga à entidade pública ou privada com destinação social, tudo na forma a ser definida pelo Juízo da execução.

CONDENAR o acusado Henrique Aparecido Leandro como incurso nas sanções do art. 33 c.c 40, VI, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 906 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

À acusada Pâmela, em vista do princípio da homogeneidade, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado Henrique, mantenho-a. Com efeito, enquanto o *fumus commissi delicti* resta verificado em sede de cognição exauriente, o *periculum in libertatis* é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Já com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos, bem como dos aparelhos celulares apreendidos.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intimem-se os acusados para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeçam-se as guias de execução cabíveis e necessárias.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA